

0036360-82.2016.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... foi réu confesso, mas referente ao tráfico de drogas, não foi ele. Referente ao tráfico, não estava na casa no dia em que os policiais entraram lá. Estava em uma casa próxima de lá e ia fazer entrevista de emprego no mesmo dia. Nunca teve conta em banco e justamente a entrevista estava agendada para 8h30min, próximo à Dutra, na Distribuidora do Tender. Esclareceu que foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0036360-82.2016.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0036360-82.2016.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 251/2016 - 8º Distrito Policial de Guarulhos, 1597/2016 - 8º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HILARIO ROBERTO FAGUNDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

GABRIEL HILÁRIO ROBERTO FAGUNDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 34, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, até o dia 08 de agosto de 2016, por volta das 07h00min, na Rua Santo Antônio do Ingá, n.º 314, casa 02, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, mantinha em depósito para fins de entrega a terceiros, 22 (vinte e duas) porções de Cannabis sativa L., substância vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 59.8 g (cinquenta e nove gramas e oito decigramas) (v. Exame Toxicológico de fls. 35/37), substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, até o dia 08 de agosto de 2016, por volta das 07h00min, na Rua Santo Antônio do Ingá, n.º 314, casa 02, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, GABRIEL HILÁRIO ROBERTO FAGUNDES, qualificado nos autos, possuía 01 (uma) balança de precisão, instrumento destinado à preparação e produção de porções de Cannabis sativa L. (v. Exame pericial de fls.

33/34), substância vulgarmente conhecida como "maconha", de natureza entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 131/133).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/60).

Devidamente notificado (fls. 159/162), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (fls. 166/168).

A denúncia foi recebida em 26 de junho de 2019 (fl. 170).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada no dia 22 de junho de 2021, foram colhidos os depoimentos das testemunhas comuns, Fernando Rosa Simão, Ronaldo Moraes da Silva e Rodrigo Emídio da Silva. Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 219/224).

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, somente pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, haja vista filiar-se ao entendimento que a balança de precisão não configura o crime do artigo 34, da citada Lei, porque sua função fica limitada a pesar a droga já fabricada, preparada, produzida ou transformada. A respeito do cálculo de pena, a pena-base poderá ser fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (certidões de fls. 182/184 e FA de fls. 179/181). Ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, inviável o reconhecimento do artigo 33, §4º da Lei 11.343, pois em se tratando de indivíduo com maus antecedentes, resta comprovado que se dedica à atividade criminosa. O regime deverá ser o fechado, devido à pena alcançada e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §2º e §3º do Código Penal. Em virtude da pena aplicada, inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP. Pelo mesmo motivo, incabível o sursis. A prisão do réu deve ser decretada, diante da reiteração em práticas delitivas, o que demonstra que, em liberdade voltará a delinquir, como já o fez (fls. 220/221).

A defesa, por seu turno, diante do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado por falta de provas para a condenação (art. 386, inc. VII, do CPP). No eventual caso de não ser o réu absolvido por ambos os delitos requereu: a) reconhecimento de que o crime do artigo 34, da Lei 11.343/2006 não restou configurado, até porque restou absorvido pelo crime de tráfico de drogas, neste ponto, a própria acusação pede absolvição por referido delito; 2) no que tange às drogas localizadas, requereu seja a conduta desclassificada para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, eis que não comprovada qualquer finalidade de mercancia da droga e porque a quantidade e a natureza do entorpecente são compatíveis com o uso. No que tange a eventual pena postulou: seja fixada a pena-base no patamar mínimo; seja aplicada a redução do artigo 33, §4º, da lei n.º 11.343/2006, eis que o réu é primário, tem bons antecedentes, não há provas de que se dedique ao tráfico ou que integre organização criminosa; seja fixado regime inicial aberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal, inclusive em atenção à novel legislação, considerando-se o quantum de pena. Por fim, seja concedido o direito de recurso em liberdade, bem como sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita (fls. 222/223).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pela portaria (fl. 02), boletins de ocorrência (fls. 04/07 e fls. 64/67), auto de exibição/apreensão (fls. 08/11), auto de entrega (fls. 12/13), documentos de instauração e apreensão (fls. 18/23 e fl. 29), laudo de constatação - balança de precisão (fls. 38/39 e fls. 62/63), exame químico-toxicológico (fls. 40/42), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de TETRAHIDROCANNABINO (THC), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado GABRIEL HILÁRIO ROBERTO FAGUNDES, em solo policial, foi indiciado indiretamente (fl. 49). Em juízo, negou a veracidade dos fatos apresentados. Explicou que, dos assaltos, foi réu confesso, mas referente ao tráfico de drogas, não foi ele. Referente ao tráfico, não estava na casa no dia em que os policiais entraram lá. Estava em uma casa próxima de lá e ia fazer entrevista de emprego no mesmo dia. Nunca teve conta em banco e justamente a entrevista estava agendada para 8h30min, próximo à Dutra, na Distribuidora do Tender. Esclareceu que foi usuário de maconha, mas nunca mexeu com drogas. A residência, onde foram encontrada as drogas, foi alugada para o interrogando há trinta dias e morava lá com sua esposa. No momento da chegada dos policiais, não estava na residência, portanto, não teria fugido. Disse que a residência possuía uma única entrada, com uma escada, como se fosse um prédio, não tem saída e nem acesso para a rua atrás ou para os lados, ou seja, ou você pula de uma altura de 20m ou 30m ou você desde e sai pelo portão. Apenas sua esposa estava no local. Narrou que foi sua esposa quem abriu a porta para os policiais e depois quando o encontrou contou tudo. Teriam dito a ela que poderia ir embora da residência, pois "só queriam ele". Acrescentou que tinham muitos produtos roubados das mercadorias que havia furtado. Esclareceu que, na época dos fatos, sua esposa era de menor de idade e tinha 17 anos. Negou que foi a pessoa que fugiu com a sacola apreendida. Não soube dizer sobre as drogas encontradas. Caso fosse uma, duas ou três porções, até concordaria, mas não possuía nenhum tipo de droga lá, pois o filho de sua esposa tem problemas de rinite, então, nem poderia fumar. Negou conhecer os policiais, nunca tinha os visto. Não soube dizer o motivo de estarem o acusando injustamente. Reiterou, por fim, que não cometeu o tráfico e, por isso, não tem como assumir. A negativa do réu, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

Mas não é só.

O policial civil FERNANDO ROSA SIMÃO, em juízo, recordou-se apenas do nome do réu, pois nunca o tinha visto antes. Relatou que foram três ocorrências juntas, sendo duas de roubo e uma de entorpecentes encontrados na posse do réu. Narrou que, quanto ao roubo de bijuterias, foram até o endereço constante no mandado e não o encontraram, mas foram informados de onde ele poderia ser encontrado, ou seja, uma rua próxima ao Jardim Cumbica. Levantado o endereço, foram até esse outro endereço. Ele tinha mandado de prisão temporária em aberto. Com a chegada dos policiais, o réu fugiu pelo telhado. Durante a fuga, ele deixou cair/lançou uma mochila. Disse que, quando adentraram a residência dele, encontraram diversos produtos de roubo das lojas Americanas. Acrescentou que, um rapaz que morava lá no mesmo quintal, Rodrigo, se prontificou e pegou a bolsa para os policiais. Dentro da mochila tinham os documentos do Gabriel, os documentos da vítima de roubo, contrato social da empresa da vítima de roubo e os entorpecentes. Não se recordou se haviam bijuterias também. Confirmou que já estavam investigando Gabriel pelo roubo e saiu mandado de prisão temporária e busca e apreensão. Negou ter visto Gabriel fugindo. Foram outras viaturas que lhes informaram que o réu havia fugido pelo telhado. Negou ter visto Gabriel dispensando a sacola. Disse que seu parceiro Ronaldo viu essa situação. Recordou, salvo engano, que eram quatro casas no mesmo terreno e Rodrigo era morador de uma delas. Rodrigo não deu nenhuma informação sobre Gabriel, mas foi ele quem lhes mostrou onde era a porta da casa de Gabriel e que ele morava sozinho na casa. Acredita que, na casa debaixo, tinham moradores que não chegaram a sair. Confirmou que coisas relacionadas ao réu foram encontradas na residência apontada, como documentos (havia parte de documentos na bolsa dispensada e parte de documentos na residência), inclusive, tinham bijuterias dentro da residência, produto de roubo, reconhecidas pela vítima. Reiterou que, dentro da mochila, tinham pacotes de maconha. Não lembra a quantidade. Negou conhecer o réu. Não se recordou sobre onde os documentos citados em audiência foram encontrados, se na residência de Gabriel ou na mochila. Questionado pela acusação sobre se foram encontrados cadernos e balança de precisão, confirmou que foi encontrada uma balança de precisão na mochila, mas não se recordou de cadernos.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil RONALDO MORAIS DA SILVA, o qual, em juízo, recordou-se do réu. Não se recorda de qual inquérito se trata, mas

tudo começou com um roubo de bijuterias na área. Roubaram as bijuterias, o carro da pessoa foi achado e levaram o celular de uma moça, salvo engano, Daniela/Daniele. Contou que, durante a noite, esta moça viu que o rastreamento do celular, um iPhone, indicava um local próximo ao 8º D.P. e foi até lá, conseguindo visualizar, andando de carro, o rapaz que teria a roubado. A vítima chamou a primeira viatura que viu, da GCM, de modo que o abordaram, o levaram ao 4º D.P. e lá o réu foi indiciado e liberado. Disse que o 8º D.P. expediu mandado de busca e apreensão e de prisão temporária, uma vez que o réu havia sido reconhecido e possuía fortes indícios de que havia participado do roubo. Narrou que, na data em que foram cumprir o mandado na residência do pai do réu, receberam a informação do real endereço de Gabriel. Quando chegaram lá, ele viu a viatura e fugiu pelos fundos. O portão estava fechado e, até chegar alguém para abri-lo, o acusado conseguiu empreender fuga, porém, visualizaram que ele dispensou uma bolsa. A testemunha disse que viu isso tudo. O réu colocou a cabeça para baixo, viu que a viatura encostou na porta de sua casa e fugiu pelos fundos. Ratificou, também, que o viu dispensar a bolsa. Na bolsa, foram encontrados diversos pertences da vítima, como bijuterias e documentos (RG, cartão, documento da empresa, etc.), bem como uma balança de precisão e drogas (maconha). Na bolsa, também tinha documento referente a Gabriel. Poucas vezes viu isso na vida, uma pessoa praticando vários crimes. Disse que na casa do réu foram encontradas outras mercadorias roubadas, não referentes ao roubo que estavam investigando, foi feita uma outra apreensão de mercadorias das lojas Americanas. Eram também acostumados a roubar carros de correio, de entrega. As mercadorias possuíam notas fiscais, foi feito um outro boletim e o réu também responde por este inquérito. Afirmou que, na apreensão, o réu não foi detido, mas que na delegacia requereram a temporária dele e o mandado de busca e apreensão. O réu fugiu e ficaram no "encalço", até o dia em que ele se apresentou no 1º D.P. Rodrigo era vizinho e foi quem pegou a mochila dispensada por Gabriel, por ser mais jovem e ter mais agilidade. A mochila foi aberta na frente de Rodrigo. Rodrigo é irmão de Renan, que é acusado de participar do roubo das bijuterias. Ao que se recorda, chegou junto, na mesma viatura, que Fernando. Disse que não tem como o réu dizer que não conhecia nem Rodrigo, nem Renan, pois eram colegas. Afirmou que Rodrigo não chegou a ser investigado, mas que em sua casa, depois de autorizada a entrada da polícia, nada de ilícito foi encontrado. Explicou que Rodrigo e Renan são gêmeos idênticos, são bem parecidos, mas toda a linha de investigação apontou para Renan, pois este morava na casa de Jennifer e lá foram encontradas as mercadorias. Depois Renan teria dito que as recebeu de Gabriel, estava com medo dele e que o questionou sobre a entrega dessas mercadorias roubadas. Contou que, quando a vítima reconheceu Gabriel, ela chamou a GCM e, quando foi abordá-lo (ele estava em um Voyage), Gabriel parou em frente à casa de Jennifer. Ela era quem pegava as mercadorias para vender. Disse que Gabriel falou "Jennifer, pega meu documento lá", na frente do GCM, Jennifer ficou sem graça e entrou. Tal atitude causou estranheza e possivelmente Jennifer "deu a fita" para o réu assaltar a vítima. Esclareceu que, quando foram cumprir os mandados na casa de Gabriel e Jennifer, desconheciam Renan, mas este estava na casa de Jennifer e foi reconhecido pela vítima. Ademais, ambos disseram que as mercadorias encontradas na residência apenas lhes foram entregues por terceiro que as achou. Contudo, Jennifer então poderia ter ligado para a vítima, já que tinham uma relação de comerciantes. Reiterou que primeiro Renan deu uma versão e, depois, deu outra, dizendo que quem lhe entregou as bijuterias foi Gabriel. Questionado pela defesa sobre ter chegado ao local junto de seu colega Fernando, respondeu que, pelo que se recorda, chegaram juntos na mesma viatura. Eram mais de uma, duas viaturas, pois era mais de um local.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de

todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção jûris tantum dá legitimidade de sua atuação" (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4a Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 V.U.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE - DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em absolvição com base na negativa de autoria isolada nos autos, quando os demais elementos de prova, como depoimento prestado por policial, dão suporte à condenação do réu. O testemunho prestado por policial é válido e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se traga aos autos, porquanto são revestidos de presunção de veracidade até que haja prova em contrário". (Grifo nosso) (Apelação Criminal - Reclusão - n.º. 2010.002225-8 - Três Lagoas - Relator - Des. Claudionor Miguel Abss Duarte Julgamento: 8/3/2010). (Grifo nosso).

Mas não é só.

A testemunha RODRIGO EMÍDIO DA SILVA, em sede policial, disse que na data dos fatos, pela manhã estava em sua residência quando ouviu barulhos do lado de fora do quintal, sendo que em seguida policiais bateram na porta da sua casa, identificando-se dizendo ser policiais, momento em que o depoente abriu a porta e franqueou a entrada dos policiais para procurar um indivíduo que acabara de fugir, sendo ele Gabriel Hilario Roberto Fagundes, o qual é morador do mesmo quintal, casa 02. Os policiais informaram que ele jogou uma mochila em outro quintal e o depoente foi quem buscou a mochila que estava sobre um telhado de uma casa vizinha. Não sabe o porquê que Gabriel fugiu. O depoente viu quando os policiais abriram a mochila e encontraram bijuterias e droga do tipo maconha, balança de precisão e outros papeis e cartões diversos (fl. 16). Em juízo, confirmou que estava no local onde os policiais foram cumprir o mandado de prisão temporária do réu. Morava no local. Explicou que é como se fosse uma "casa de pensão", várias pessoas moram. Disse que

só possuía ciência de que Gabriel morava no mesmo quintal que ele e o conhecia por serem vizinhos. Narrou que, na data dos fatos, a polícia entrou no quintal e estava dormindo, mas acordou com a gritaria dos policiais por voltas das seis horas da manhã. Bateram na porta, perguntou quem era, de modo que se apresentaram como sendo da Polícia Civil. Abriu a porta perguntando o que estava acontecendo. Perguntaram-lhe se alguém havia entrado em sua casa, o que negou e, ao mesmo tempo, deixou que os policiais entrassem para confirmar. Perguntaram, ainda, se o depoente conhecia Gabriel e respondeu que ele morava lá embaixo, mas não o viu. Contou que, como Gabriel não foi encontrado, os policiais disseram que teriam que levá-lo como testemunha, o que ocorreu. Negou que tenha visto os policiais encontrando alguma coisa na casa de Gabriel, pois mora lá na parte de cima e Gabriel embaixo. Negou que tenha pegado alguma mochila dispensada na fuga, pois estava dentro de sua casa. Negou que a versão dos policiais fosse verdadeira. Disse que não viu nada e, inclusive pediram para que ele ficasse sentado no sofá. Afirmou não ter visto nada que foi apreendido na casa de Gabriel e não acompanhou nada. Explicou que só conhecia Gabriel porque moravam no mesmo quintal, nem tinham muita intimidade, só o respeito de vizinhos. Confirmou sua assinatura referente ao depoimento prestado na fase policial. Explicou que estava sendo conduzido pelos policiais e nem sabia o que estava acontecendo, inclusive, apenas lhe falaram para assinar o documento para ser liberado, o que fez. Não leu o que assinou.

Pois bem, a despeito da negativa do acusado, diante dos depoimentos firmes e seguros dos policiais que participaram das investigações, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que GABRIEL mantinha em depósito os entorpecentes apreendidos para fins de tráfico, não se podendo cogitar em uma absolvição por insuficiência probatória.

Os policiais civis foram enfáticos, harmônicos e seguros ao afirmarem que o réu ao perceber a chegada deles no local, fugiu pelo telhado das casas vizinhas, tendo lançado a mochila contendo as drogas, a balança de precisão e outros objetos, inclusive documentos pessoais e bens produto de roubo, delito pelo qual o réu foi condenado definitivamente como autor do crime patrimonial (autos nº 0027391-78.2016.8.26.0224, da 2ª Vara Criminal local, conforme certidão de fls.227/228). Nessa seara, que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário. Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza e quantidade de droga apreendida (22 porções de Cannabis sativa L., substância vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 59.8g), da forma como estavam embaladas e acondicionadas, além das circunstâncias do episódio, tendo sido inclusive apreendido junto com as drogas uma balança de precisão usada para pesagem do entorpecente..

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP "RT" 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito" (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: "o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo" (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido;

J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: “considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

Outrossim, a alegação da defesa do acusado Gabriel ser usuário não afasta a certeza de seu envolvimento com o tráfico de drogas e do destino do entorpecente apreendido, eis que comum o envolvimento de usuários com o tráfico, inclusive para manter seu vício.

Descabida, portanto, a tese defensiva de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que não logrou a nobre defesa comprovar que o entorpecente apreendido destinava-se realmente ao consumo do réu, até porque nem mesmo o réu alegou que a droga era para seu consumo, preferindo negar a posse do entorpecente.

Restaram, portanto, bem evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu, sendo certo que sua conduta e os elementos de prova constantes dos autos apontam na real direção da traficância ilícita de entorpecentes, comportamento previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

De outra banda, as provas colhidas no decorrer da instrução criminal são seguras no sentido de que o acusado possuía 01 (uma) balança de precisão eletrônica, instrumento destinado para preparação e medição das porções das drogas, (auto de exibição e apreensão de fls. 08/11 e laudo pericial de fls. 38/39 e fls. 62/63). Todavia, não é o caso de condenar o réu também pelo artigo 34 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que dita conduta constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de delito de alcance mais amplo, no caso, o tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Assim, considerando que o réu, no mesmo contexto fático, mantinha em depósito os entorpecentes apreendidos e possuía 01 (uma) balança de precisão, a qual, provavelmente, seria utilizada para a divisão do entorpecente em porções menores, deve responder apenas pelos delitos tipificados no artigo 33, da Lei n.º 11343/06, o qual absorve o delito tipificado no artigo 34 do mesmo diploma legal, aplicando-se o princípio da consunção.

Sobre o tema, é o entendimento de Luiz Flávio Gomes:

“Cuida-se de delito subsidiário, ou seja, praticando o agente, no mesmo contexto fático, tráfico de drogas e de maquinários, deve responder apenas por aquele, ficando este absorvido (o que não impede o juiz de considerar essa circunstância na fixação da pena). Nesse sentido: “Embora se trate de condutas previstas em dispositivos legais distintos (arts. 12 - atual art. 33 - e 13 - atual art. 34), comete somente o delito de tráfico o agente que, no mesmo contexto fático, é surpreendido mantendo sob seu poder e guarda tóxico e na posse de maquinismo para

manipular entorpecente". ("Lei de Drogas Comentada", Ed. RT, 2ª edição, p. 200).

Nesse sentido também já se manifestou a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecentes. Condenação pelo art. 28, caput, da lei 11.343/06. Recurso ministerial. Pedido de condenação pelos crimes do art. 33, caput, art. 34, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. Tráfico de entorpecentes. Recurso ministerial. Pedido de condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Conjunto probatório seguro e inequívoco. Declarações policiais em consonância com demais indícios colhidos aos autos. Crime de tráfico caracterizado. Condenação que se impõe. Associação para o tráfico de drogas. Tese condenatória afastada. Caderno processual desprovido de provas seguras do vínculo associativo permanente e estável. crime não caracterizado. Absolvição mantida. Guarda de objeto destinado à preparação, produção ou transformação de drogas. art. 34, caput, Lei 11.343/06. Tese condenatória afastada. Princípio da consunção. Crime meio para a perpetração do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Insuficiência de provas quanto à efetiva destinação do objeto. Absolvição mantida. Pena. Pena-base. fixação no mínimo legal. Atenuante da menoridade. reconhecimento. Observância à súmula 231, do stj. Aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da lei 11.343/06. Possibilidade. Requisitos exigidos para a concessão da benesse satisfeitos pelos apelados. Recurso parcialmente provido". (TJPR - Apelação Criminal nº 644379-0 Des. Rel. Sônia Regina de Castro, DJU 02/09/2010 - grifos nossos).

"HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE E GUARDA DE MAQUINÁRIO E DE ESTOCAGEM DE MATÉRIA-PRIMA DESTINADOS À MANUFATURA DE ENTORPECENTES (ARTS. 12, § 1º, I, e 13 DA LEI Nº 6.368/76, ATUALMENTE PREVISTOS NOS ARTS. 33, § 1º, I, e 34, DA LEI Nº 11.343/06). CONDUTAS TÍPICAS QUE CONSTITUEM MEIO NECESSÁRIO OU FASE NORMAL DE PREPARAÇÃO OU EXECUÇÃO DE DELITO DE ALCANCE MAIS AMPLO (FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTE). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O princípio da consunção em relação aos crimes de posse e guarda de maquinário e de estocagem de matéria-prima destinados à manufatura de substâncias entorpecentes pode ser aplicado, uma vez que ditas condutas constituem meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de delito de alcance mais amplo, no caso, a fabricação de entorpecente. 2. Conclui-se que o intuito do legislador foi punir, por exemplo, o agente que constrói um laboratório para refino de cocaína, independentemente da sua efetiva produção, ainda que a posse das máquinas e dos objetos em questão não seja, isoladamente, considerada ilícita (tais como, no caso em exame, de baldes e de um liquidificador); ou sancionar aquele que mantém em depósito matéria-prima destinada ao refino ou à produção de drogas, mesmo que a estocagem dessa, por sua natureza, não constitua, per se, crime (no caso concreto, de solução de baterias, livremente revendida com fim específico de regeneração de cargas elétricas em baterias, e de barrilha, utilizada no tratamento de água para piscinas e para outras finalidades lícitas). 3. No caso em exame, pelo que se vê da denúncia, tanto a posse da matéria-prima, como a dos maquinismos/objetos, visava a um fato único: a produção de entorpecente (merla) pelo paciente naquele local, para posterior comercialização da droga. 4. Está patente nos autos a existência de uma estrutura destinada ao tráfico de drogas, na modalidade de fabricação. 5. Ordem concedida." (HC 100.946/GO, STF, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, J. 25/10/2011, DJe 27/02/2012) (grifos nossos).

"Por outro lado, no tocante ao recurso ministerial requerendo a condenação do réu também pelo crime capitulado no artigo 34, caput, da Lei nº 11.343/2006, a meu aviso, não merece acolhimento, já que os objetos encontrados na diligência policial, descritos no auto de exibição e apreensão, quais sejam, duas balanças de precisão, fita adesiva, rolos de papéis alumínio, dois frascos de éter, um frasco de acetona, uma prensa hidráulica, baldes, bacias e pratos, estavam relacionados com o crime de tráfico de entorpecentes exercido pelo réu, pelo que tal fato, em meu sentir, deve ser absorvido pela norma mais grave" (TJESP, Apelação Criminal nº. 0039558-62.2013.8.26.0506, Relator Desembargador SÉRGIO COELHO, DJe 04-10-2018).

"Contudo, não se há falar em condenação também pelo artigo 34 da Lei nº 11.343/06, como almeja o Ministério Público. Isso porque a existência de balanças de precisão e de embalagens - de fato instrumentos utilizados no comércio da droga -, já estão subsumidas no contexto do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ainda, conforme se depreende de fl. 106, a substância apreendida à fl. 47 que poderia ser usada para aumentar o volume do entorpecente teve resultado negativo em relação à presença de substância proscrita ou controlada (Portaria Anvisa 344/98), de tal sorte que, não estando efetivamente provada a tipicidade, não se pode querer condenação. Com efeito, o artigo 33 da Lei de Drogas relaciona-se com a droga, ao passo que o artigo 34 do mesmo diploma faz referência aos objetos destinados à sua produção. No caso em testilha, não restaram demonstrados contextos autônomos, de tal sorte que é de rigor reconhecer a natureza subsidiária do tipo do artigo 34, ou por outras palavras, à luz do princípio da consunção, o referido delito deve ser absorvido pelo tráfico, pois cometido no mesmo contexto fático, sendo meio para a prática do crime-fim" (TJESP, Apelação nº. 0085325-65.2015.8.26.0050, Relator Desembargador CARLOS MONNERAT, julgado 25-8-2016).

Por fim, de rigor o afastamento da imputação e absolvição do réu do delito previsto no artigo 34 da Lei de Drogas, porquanto prevalece o entendimento de que as figuras típicas deste artigo são subsidiárias, incidindo apenas quando o agente não incorre em nenhum dos núcleos previstos no "caput" do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada a culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado pelo delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, absolvendo-o do delito tipificado no artigo 34 do mesmo diploma legal, eis que atípica esta conduta, que se encontra absorvida pela primeira.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, na primeira fase, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, eis que possui condenação definitiva por fato anterior aos apurados nos autos, embora não seja apta a gerar reincidência, em razão do trânsito em julgado ser posterior (processo nº 0027391-78.2016.8.26.0224, da 2ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução provisória da pena nº 0016156-22.2017.8.26.0502, da Vara das Execuções Criminais, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 216/217, certidão de objeto e pé de fls. 227/228 e F.A. de fls. 180/181). Assim, nessa primeira fase, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Observo que a quantidade de entorpecente apreendido não se mostra excessiva a justificar o aumento da pena-base (22 porções de Cannabis sativa L., substância vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 59.8g).

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual retorno as penas no patamar mínimo, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena a serem analisadas. Presente por outro lado, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Tóxicos. A despeito os maus antecedentes do acusado, considerando as circunstâncias dos fatos, considerando que a condenação anterior se refere a fatos antigos e, desde então, o réu não se envolveu com outras práticas criminosas, bem como considerando que o antecedente não é por delito de tráfico, entendo justificável a aplicação do redutor em questão, todavia, em razão dos maus antecedentes, adequada a redução em aptamar intermediária. Assim, reduzo as penas de 1/2 (metade), fixando a reprimenda, em definitivo, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (0

art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Considerando a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada e o fato do réu ser tecnicamente primário, fixo o regime inicial ABERTO, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Seguindo o mesmo entendimento, verifico que o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 3º, do C.P. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quase sejam, prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal, pelas mesmas razões quando da fixação da pena-base.

O réu responde o processo em liberdade, não sobrevivendo razões que demonstrem a necessidade de segregação cautelar, razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR GABRIEL HILÁRIO ROBERTO FAGUNDES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e § 4º da Lei Federal nº. 11.343/06, ao cumprimento de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, substituído por prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), além do pagamento de 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal. Outrossim, ABSOLVO GABRIEL HILÁRIO ROBERTO FAGUNDES, da imputação que lhe move a Justiça Pública, por infração ao artigo 34, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Poderá apelar em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º, do C.P.C.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 04 de março de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA